壹、称姓

一、婚生子女称姓(限父或母姓) §1059Ⅰ ⇒變更

1.取得：19~§1059Ⅰ：子女從父姓，招贅婚從母姓，約定從其約定／74~增訂但母無兄弟／96~書面約定／戶籍§49Ⅰ前 99~§1059Ⅰ：約定不成抽籤

↳男女比(1:3~1:4)

2、變更

(1) 未成年前父母書面約定變更(§1059Ⅱ)：非親权內容，縱被停止有約定變更之权利

(2) 子女已成年得變更(§1059Ⅲ) ⇒ 96~99 §1059Ⅲ 經父母書面同意

(3) §1059Ⅳ：§1059Ⅱ、Ⅲ 以1次為限

(4) 法院裁判(§1059Ⅴ) ⇒修法理由：§1059Ⅴ④含修法前之曾有或現有未盡扶養义務

二、非婚生子女之称姓

1.取得：從母姓(§1059-1Ⅰ前)，出生登記前已經認領則§1059Ⅰ 書面約定之

↳~96舊法無明文 ⇒ 33院2773：認領前從母姓，認領後依~96§1059Ⅰ 從父之姓

2、變更

(1) 經生父認領(§1059-1Ⅰ後 $\xrightarrow[\text{用}]{\text{適}}$ §1059Ⅱ~Ⅳ) (林：未登記生父即書面約定或自行更改從父姓之效力有疑問)

(2) 法院裁判(§1059-1Ⅱ) (note：準正後應適用§1059)

三、養子女之称姓

1.舊法：19~96 §1078 從收養者之姓，夫妻收養適用§1059

2、取得：§1078Ⅱ 收養登記前，書面約定從父、母或原姓，單獨收養由收養者決定

↳無法決定時無§1059Ⅰ之準用 ⇒無法抽籤 ⇒別無他法

3.變更(§1078Ⅲ $\xrightarrow[\text{用}]{\text{準}}$ §1059Ⅱ~Ⅴ)

(1) 單獨收養者無準用可能，亦不得變更為原姓氏

(2) 25院1602：不得兼用本姓，本姓之加入只能認係名之一部，非複姓

四、裁判變更之注意事項(§1083-1)：依§1059Ⅴ、1059-1Ⅰ、Ⅱ、1078Ⅲ 裁判時準用§1055-1 ⇒ BIOC 及§1055-1 7款事由

貳、親权

一、親子法沿革：家本位→母本位→子女本位

1.性質：親权有权利亦為义務 ⇒不可拋棄(SC 28渝上1719例、38台上1714例)

2、保护、教養之权利：对外关係，有权要求第三人不妨害(ex：子女返还請求权)

3.保护、教養之义務：对內关係 ⇒具体如同意权、懲戒权、法代权 ⇒親权之濫用實質上為教養及保护义務之違反(黃宗樂、林)

4、§1084Ⅰ：子女應孝敬父母

(1) 此條應為道德上訓示規定，子女不問成年與否 ⇒僅具教育性作用，意义不大

(2) SC 74台上1870例 將§1084Ⅰ與§1145Ⅰ⑤失权規定巧妙結合，賦予§1084Ⅰ法律上意义(林)

二、行親权之人

1、父母：原則本生父母，出養後転由養父母親权人 (SC 70上2305例)

2、父母一方死亡、被停止親权時，由他方行之，即使再婚，仍為親权人 (SC 22上1123例、23抗1711例)

↳ 再婚之母未與其未成年子女同居，則不得行使親权 (SC 32永上304例)

3、非婚生子女經认領 (§1069-1 $\xrightarrow[\text{用}]{\text{準}}$ §1055~1055-2)

4、舊法：未婚之未成年，无完全行為能力，為法律行為尚須法代同意，无法对子女行使親权，依§1091應置監护人

三、服親权之人

1、限未成年子女

2、舊法：未成年已結婚取得財產上能力，財產行為上不必服親权，但身分行為上仍須服親权 (舊§981、1049但、1076-2Ⅱ、1080Ⅲ)

四、內容

1、居住所指定权 (§1060)

(1) 通：§1060與§21所謂之住所涵义有所不同，應指居住所指定权 (立法論：應置於§1084後)

(2) 父母不得提起請求子女同居之訴 (SC 52台上3346例) ⇒ 通：行使懲戒权，亦不妨停止支付教養費用，使子女遵從 ⇒ 指定权薄弱，无強制性

2、子女交还請求权 (通)：父母得本於親权人身分向扣留子女之人請求交还子女

(1) 无明文，但通说皆肯认之，SC 50台上1031例亦肯认

(2) 家事§104Ⅰ⑤、107Ⅰ、194：交付子女事件為親屬非訟事件

3、懲戒权 (§1085)

(1) 應為實施保护教養所必要，程度應按背景、性別、年齡、过失輕重、健康 (通)

(2) 成年之懲戒

A、否定说 (史、鼎、曹、李宜琛、棋、通)：保护教養权限未成年 ⇒ 懲戒权限未成年

B. 肯定说 (胡)：文义解釋，惟无保护教養权，无实益

C、折衷说 (戴炎輝、戴、林)：應與§1085子女應為相同解釋 ⇒ 實質論上，許剛滿20歲之子女，对父母之懲戒得行使正當防衛，有違孝道之立法意旨

↳ 民法特用曖昧其詞 即立法者有意使裁判者有彈性空間

4、法定代理权 (§1086Ⅰ) (ex：§974、981、1049但、1076-2Ⅱ、77、79、85、76、1067Ⅰ、1063Ⅲ、民訴§47、家事§65)

(1) 舊法：利益衝突未明文 (SC 70上954例—解：可另選監护人)

(2) 立法理由：廣义解釋 ⇒ 含§106自己、双方代理

(3) 立法理由：民訴§51係声請特別代理人之程序規定，與§1086Ⅱ實体規定不同

↳ ex：法院已依§1086Ⅱ ⇒ 該特別代理人即就該事件為法代 ⇒ 无民訴§51，須无先§1086Ⅱ才有民訴§51

(4) §1086Ⅱ不受声請人声請限制，得依职权為之 (ex：遺產分割事件) (高院98座談会民事1)

5、子女特有財產之管理 (§1088)

(1) 特有財產（§1087）：未成年子女因繼承、贈与或其他无償取得之財產

(2) 有償取得之歸屬（法未明文，因立法時工商业不發達，取得之財產除法定方式外不多）

A、父母说（舊学说：緣、胡、黄右昌、李宜琛）

B、子女说（新学说：林、戴、棋、振、鑑、史）：子女勞力所得須保障以貫徹人格獨立原則

(3) §1088Ⅰ：父母共同管理 ⇒ 含权利及义務

A、对內為义務 ⇒ 保护、利用、改良子女財產（对父母无益）

B、对外為权利：父母得以占有人身分向侵奪子女財產之第三人請求交还（SC 37上8467例）（林：对外主張权利即对內履行管理义務）

6、对子女特有財產收益权（§1088Ⅱ本文）

(1) 此條无义務成分 ⇒ 違反BIOC（林：应仿外國立法例，否定父母收益权，確保子女利益）

(2) 17親屬法草案§53Ⅱ但：父母得為子女利益使用、收益或处分之 ⇒ 反面解釋：非為子女利益父母无收益权

7、对子女特有財產处分权（§1088Ⅱ但）：应有比例原則

(1) 胡、林：廣义解釋 ⇒ 法律上处分、事实上处分（法律上行為含物权、債权行為）（SC 110台上1902：含買賣、保证、簽發票据、贈与）
即負担行為
↳ ex：吃子女之蛋糕，对外不生問題，僅对內有§179 or §184

(2) 代理（SC 53台上1456例、53第1次民刑庭決议(二)、32上1876例）：应以子女名义為之（顯名代理主义）

A、SC 53台上3747、58台上2308、59台上1898：法无明文，代理权无限制

B、SC 83台上1224：未成年子女自為处分，同意应以§77，代理則受§1088Ⅱ但限制

C、SC 86台上344、戴瑀如、黄詩淳、SC 93台上2282、98台上1234：同意及代理均須考量BIOC

D、林：僅处分有§1088Ⅱ但適用

(3) SC 51台上2108例：子女利益应斟酌当時一切情事，ex：清償子女債務处分子女繼承遺產
↳ SC 42台上126例：非為子女利益以特有財產担保，应不许之

(4) 保证非处分 ⇒ 代子女為保证之效力

A、有效说（SC 53台上2611例—廢）：財產上行為法代均得代理之；保护交易安全（戴、棋）

B、无效说（SC 110台上1902、113台上417、103台上2650）：係处分，按§1088Ⅱ但无效
（林、李玲玲）：非处分，但保证僅对保证人有害无利 ⇒ 法代权以損害子女為主要目的 ⇒ §148Ⅰ ⇒ 越权行為於子女成年承认前不生效力

(5) 違反之效力

A、无效说（戴東雄、戴、SC 113台上417、110台上1902、69台上1309、59台上1898、58台上2308、57台上3314、1237、54台上2929、944、53台上3747、48台上1407、44台上826）：§1088Ⅱ但係禁止規定

B、有效说（戴炎輝、振、棋、许澍林）：父母依委任規定向子女負損賠責任

C、无权代理说（史、高鳳仙）

D、无权处分说（陳計男）

E、无償行為无效，有償行為有效说（鑑）

F、債权行為有效，物权行為无权处分並有善意取得適用说（李玲玲、林）：对外应回歸財產法，惡意第三人須待其成年後追认才確定

(6) 林：立法論上亦应刪除，因有違BIOC

五、行使 (§1089)

1、舊法(~85)：J365 以意思不一致由父行使違憲

2、§1089Ⅰ前：以父母共同行使為原則

(1) SC 75台上1244、史、模、林：須生父与生母有婚姻或尚在同居才有適用

(2) 離婚後除有約定否則僅得由一方行使 (林)

3、§1089Ⅰ中：父母一方不能行使权利，由他方行使之；§1089Ⅰ後：不能共同負担時，由有能力者負担之

↳ 不能：兼指事实与法律上不能（坐牢、重病、失蹤），行使困難不屬之（路途遠、上班忙） (SC 62台上415例)

4、§1089Ⅱ：对重大事項意思不一致，法院依BIOC酌定之

(1) 重大事項(須為特定事件)：就业、就学、留学、皈依、婚姻、營业許可

(2) 酌定：法院參考父母之意見，何者有利則採何者，非逕為決定取代父母之意思 ⇒ 法院不代行親权 (模、林)

(3) §1089Ⅲ：裁判前應听取未成年子女、主管机关或社福机構之意見

5、96~增§1089-1本文：父母分居達6月↑ —準用→ §1055~1055-2 離婚

(1) 即事实上别居

(2) 但：法律另有規定 指 家暴§13Ⅱ③、⑥（改定暫時親权行使及負担之人）、兒少§71、§1090（停止親权亦法律上不能）

↳ 林：但書之有正当理由排除原因不明，分居6月仍有定親权人必要 ⇒ 但書畫蛇添足，立法論上應予刪除

6、成年人共同監护人規定无漏洞，无須準用§1089 (SC 103台上2073、103台抗622裁)

六、停止 (§1090)

1、舊法 ~96：濫用親权由最近尊親屬或親屬会议糾正之。糾正无效時得請求法院停止其权利之全部或一部

2、声請人：他方、未成年子女、主管机关、社福机構、其他利害关係人

3、濫用：懲戒过当、濫用法代权為保証、对特有財產管理失当、非為子女利益处分特有財產、替子女拋棄繼承

↳ 得宣告停止一部或对子女权人中一人之親权 (史、模、羅、林)

4、双方均被停止親权 ⇒ §1091 應置監护人

5、效果

(1) 血緣关係、扶養义務(§1114①)仍繼存

(2) 停止全部時，得類推§1055Ⅴ酌定会面方式 (林)

6、程序

(1) 舊民訴§592、593：受判決後，撤銷停止親权之訴，原告未明文但解釋上應以受停止人、未成年子女及利害关係人任之，以現行親权人或監护人為被告

(2) 新家事§104Ⅰ③、74、3Ⅴ⑩ 屬類非訟事件：撤銷時受停止人、未成年子女、其他利害关係人得為声請人，現行親权人或監护人為相对人

7、撤銷：宣告停止之原因消滅後，得声請撤銷之